

1501398-14.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189692/2021 - 02º D.P. DIADEMA, 19031431 - 02º D.P. DIADEMA, 1454/21/123 - 02º D.P. DIADEMA, 2189692 - 02º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501398-14.2021.8.26.0537 - Controle nº 2021/001000

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2189692/2021 - 02º D.P. DIADEMA, 19031431 - 02º D.P. DIADEMA, 1454/21/123 - 02º D.P. DIADEMA, 2189692 - 02º D.P.

DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Henrique Torres Palma

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

JONATHAN HENRIQUE TORRES PALMA, qualificado às fls. 07 e 21/22, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque no dia 14 de julho de 2021, por volta das 08h00, Avenida Maria Cândida de Oliveira, Vila

Nogueira, nesta cidade de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 138 embalagens plásticas contendo 64,6g da droga cocaína, 82 embalagens plásticas contendo 9,5g da mesma droga, na forma de crack, e 80 embalagens plásticas contendo 177,6g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 12/13 e laudo de constatação provisória de fls. 18/20, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl. 62/64), foi nomeado Defensor Público ao acusado, e apresentada defesa inicial às fls.122/123. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 08/10/21 (fls.125) e certificada a citação positiva do Réu a fl.164.

Na primeira audiência de instrução, debates e julgamento foi ouvido um policial, nesta audiência as Partes desistiram da oitiva do policial Vinicius Pereira, ainda doente, o que foi homologado, sendo interrogado o réu ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, seguiu-se com os debates orais (tudo em mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação da pena base acima do mínimo diante da quantidade e nocividade da droga cocaína, com a agravante da multirreincidência embora presente a atenuante da confissão, discordando da redução da pena e de sua substituição pela pena restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade, mais a perda do numerário apreendido.

Já o d. Defensor Público reiterou o pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a figura de olheiro, ou que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com a atenuante da confissão se considerada a extrajudicial, mais o redutor da pena ainda que em grau menor, e sua substituição, fixando-se regime aberto e possibilidade de recurso em liberdade em virtude da detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.12/13, nos laudos de constatação e no definitivo (fls.18/20 e 92/94), ambos positivos para as drogas maconha e cocaína, além das fotografias de fls. 14/16.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais militares (fls. 05 e 06) efetuavam patrulhamento ostensivo no local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que avistaram o indiciado JONATHAN HENRIQUE TORRES PALMA passar a empreender fuga, correndo diante da aproximação da viatura policial. Desembarcaram e foram ao encalço do indiciado, logrando êxito em detê-lo após poucos metros, já na Viela Salsa e Merengue. Durante o procedimento de busca pessoal foi localizado na posse do indiciado, no bolso da blusa de moletom, uma sacola plástica contendo 138 porções de pó branco aparentando à cocaína, 82 pedras aparentando à "crack", 80 porções de erva verde aparentando à maconha, além da importância de R\$98,00 em dinheiro. Indagado a respeito dos fatos, o indiciado confessou informalmente que se encontrava no local comercializando drogas, sendo seu 3º (terceiro) dia nesta atividade ilícita.

Sob o crivo do contraditório o policial Marcelo Alves reiterou que visualizaram o

réu e assim que ele os viu, correu, sendo alcançado e detido. Revistado, em poder dele estavam as drogas e o dinheiro, tendo ele lhes confessado, informalmente, estar no local traficando.

O réu, em solo policial (fl. 07) respondeu que estava no local comercializado drogas, sendo seu terceiro dia nesta atividade ilícita. Que comercializa a unidade das drogas maconha, cocaína e crack pelo valor de R\$ 5,00, sendo o valor encontrado, a saber, R\$98,00, proveniente da traficância realizada nesta data. Por fim, relata que já foi preso em razão do tráfico de drogas.

Em juízo o acusado inovou, ou seja, alegou que era apenas olheiro, que ficava ali avistando, e ao ver os policiais, avisou o rapaz/traficante e correram. Dali dez minutos o policial voltou com uma bolsa com as drogas e disse que teria que levar alguém, mas sua função era olhar a viatura vir. Já foi processado por tráfico e assalto. Nega ter confessado ao delegado de polícia que estaria vendendo, pois já tinha dito que só olhava. Não viu onde os policiais encontraram as drogas. Acha que pelo motivo de não ter delatado o traficante, os policiais disseram que ele seria levado como traficante. Nada tem contra os policiais e nem os conhecia, foi a primeira vez que os viu.

Logo, o interrogatório com as confissões informal e a extrajudicial do acusado, que não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, e por isso considerarei também a embasar a condenação, em que pese o réu tente fazer crer nessa audiência em continuação, que ele estivesse apenas trabalhando para o tráfico, como olheiro, fato este que tão pouco lhe favorece, até porque não fez prova nesse sentido, pelo contrário, o réu nada tem contra os policiais/testemunhas, que sequer conhecia. Mesmo que o policial Vinicius não tenha sido ouvido em juízo, pois doente, tanto que a própria Defesa desistiu de sua oitiva, o que não lhe favorece.

Dito isso, e por ausência de prova acerca de ser o réu mero informante, não se tem como acolher pedido da Defesa de desclassificação para a figura do art. 37 da Lei Especial. Até pelas confissões do réu no sentido de ser o traficante, tanto que já condenado antes por crime análogo.

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo e guardar, condutas perpetradas pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaína), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido, a reincidência específica, são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do

delito somado à excessiva quantidade de narcótico apreendido (300 invólucros totais), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, presente a circunstância agravante da dupla reincidência (fl. 81 - condenação por tráfico junto à 1ª Vara Criminal de Sumaré) a qual compenso com a atenuante da confissão, que por envolver a personalidade do agente, são igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal" (STJ, REsp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, DJE 4.9.2012), e a aumento pela reincidência atestada a fl. 37 - condenação por roubo junto à 2ª Vara de Paulínia a aumentar a pena para de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu reincidente, específico, a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal dada sua maior dedicação ao crime e maior envolvimento com este.

Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a reincidência do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, além da grande quantidade e variedade de drogas. Ademais: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional." (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo (agente não é primário). Ademais: "Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617.

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto DJe. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº

34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obterá um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de seis meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra JONATHAN HENRIQUE TORRES PALMA, qualificado às fls. 07 e 21/22 e o faço para condená-lo à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 680 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, por ser condenado assistido pela DPE.

Decreto a perda de valores apreendidos nestes autos, (fls.12/13) com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob pena de extração de certidões da Sentença para a Procuradoria Geral do Estado (dívida ativa).

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA